

1500486-83.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/07/2022
... da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Criminal
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500486-83.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500486-83.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica (Violência Doméstica Contra a Mulher)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDRÉ LUIZ HORNEAUX DE ALMEIDA

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

ANDRÉ LUIZ HORNEAUX DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e no artigo 129, §13, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na exordial, em ocasião de calamidade pública, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas

protetivas de urgência em favor de L.L.S.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas na exordial, o acusado agrediu L.L.S., com quem manteve relacionamento amoroso, causando-lhe lesões corporais de natureza leve

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma das testemunhas arroladas na denúncia. Foi homologada a desistência manifestada pelas partes quanto à oitiva de uma testemunha policial militar. Ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos relativos à fixação da pena e do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, por falta de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 20/21, pelo relatório médico de fls. 25, pela fotografia de fls. 26, pelos documentos encartados às fls. 27/30, pela prova oral produzida em Juízo, bem como pelos demais elementos de prova amealhados aos autos.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado disse que tinha ciência de que não poderia se aproximar ou manter contato com a vítima, porém possui com ela um filho e, devido a vítima ser mãe apenas daquela criança, queria auxiliá-la, por ter experiência com seu outro filho com treze anos. Contou que a vítima possui transtorno bipolar e já submeteu-se a tratamento por uso de droga e de álcool. Disse que quando o bebê nasceu, a assistente social lhe entregou a criança à sua guarda, mas deixou a criança com a vítima, por consideração a ela. Alegou que a vítima não cuidava a criança de forma correta e, certo dia, discutiram, a vítima avançou em sua direção e a empurrou. Disse que, em razão desses fatos, foram deferidas as medidas protetivas e a vítima mudou-se para outra cidade. Contou que, passados quatro meses, mantiveram contato pelo aplicativo Whatsapp e, em determinada data, a vítima retornou a esta cidade e foi à sua porta, pedindo que retomassem o relacionamento. Disse que voltaram a relacionar-se, porém, alguns dias depois, a vítima tornou a alterar-se, proferindo ofensas contra si e sua família. Alegou que, na data dos fatos, após chegar de seu trabalho, combinou com a vítima de irem ao mercado próximo à casa em que estavam residindo juntos e, a caminho do mercado, a vítima pediu que parassem para tomar cerveja. Contou que consumiram bebida alcoólica juntos, mas, em dado momento, a vítima alterou o comportamento e pediu para que fossem à praia. Disse que, então, discutiram e a vítima começou a agredi-lo, apertando seu pescoço. Alegou que, então, empurrou a vítima, fazendo com que ela cortasse a testa. Disse que foi à casa de sua mãe, mas retornou à residência onde estaria morando com a vítima para buscar suas roupas, mas não conseguiu sair de lá porque a vítima o trancou. Disse que ficou sentado dentro da casa, apenas aguardando. Alegou que não procurou a vítima para manterem contato, mas, sim, o contrário. Disse que não conhecia os policiais que o abordaram e alegou que o policial depoente não integrava a primeira equipe policial que chegou à casa, tendo visto o policial depoente somente na delegacia. Alegou ter dito aos policiais que não saiu da casa porque a chave estava com a vítima. Disse que os fatos que narrou foram presenciados por sua mãe e também por conhecidos que estavam na adega onde tomou cerveja com a vítima.

Contudo, a negativa e a versão apresentada pelo acusado, além de não serem críveis, estão isoladas no contexto probatório.

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou ter sido agredida pelo acusado e confirmou ter o réu descumprido a decisão judicial que impôs as medidas protetivas. Declarou que não reside como réu desde o mês de setembro do ano de 2021 e passou a residir na cidade de Araçatuba, porém retornou a esta comarca porque o acusado pediu para que trouxesse o filho de um ano e um mês que possuem em comum. Relatou que, a fim de permitir que o filho mantivesse contato com o pai, retornou a esta cidade, alugou uma casa e, passadas duas semanas de estada, os fatos ocorreram. Narrou que acordou com o acusado que ele ficaria com o filho algumas vezes, mas que ele não deveria aproximar-se de si. Disse que o acusado havia pedido para que fosse à casa da mãe dele, a fim de estabelecer um contato familiar e, na data dos fatos, o fez. Declarou que lá chegando, o acusado não estava na casa da genitora e esta pediu para que o procurasse. Consignou ter acreditado que não correria nenhum risco e encontrou o acusado em uma adega, onde ele já estava bebendo, embora fosse ainda manhã. Disse que o réu ofereceu-lhe bebida e recusou. O réu disse que não sairia daquele local, mas respondeu a ele que ali não permaneceria com seu filho e foi embora. Narrou que o acusado começou a enviar mensagens pelo aplicativo Whatsapp, dizendo-lhe que “iria sofrer”, que “iria ver”, e que “iria retalhá-la”. Disse que permaneceu fazendo suas tarefas fora de casa com seu filho e o acusado começou a enviar mensagens, por volta de 15 horas, dizendo que estava na porta de sua casa. Narrou que, ao retornar para sua residência, por volta de 16 horas, pois precisava providenciar os cuidados de seu filho, encontrou o acusado em sua porta, dizendo que queria entrar no local. Consignou que o réu segurava uma cerveja e estava alterado, provavelmente por consumo de entorpecentes, que ele costumava usar em excesso. Declarou que estava com seu bebê em seu colo, no “canguru”, quando o acusado a agrediu, desferindo dois socos em sua cabeça, machucando sua testa, que sangrou, e causou inchaço. Narrou que afastou seu filho, para protegê-lo dos golpes e ele não foi atingido. Relatou que, após agredi-la, o acusado entrou em sua casa e recusava-se a sair, razão pelo qual o trancou no local, pois estava com medo, e comunicou a genitora do acusado sobre o ocorrido. Disse que, naquela data, havia muitos vizinhos na rua, que presenciaram a agressão e estes acionaram a polícia, que foi ao local. Consignou que o acusado permaneceu dentro de sua casa por cerca de meia hora, transtornado, e a ofendia e ofendia a própria mãe, sendo que, quando os policiais chegaram, o réu ofendeu a policial feminina e, mesmo tendo os policiais tentado retirá-lo de dentro do imóvel, o acusado recusava-se a sair, alegando aos policiais que a havia agredido, acusando-a de não cuidar direito de seu filho e porque estaria vendendo drogas na praia com a criança. Declarou que, já na delegacia, o acusado iniciou um tumulto e gritava, dizendo que iria procurá-la quando fosse liberado. Esclareceu que as medidas protetivas estavam em vigor desde o mês de agosto do ano de 2021 e declarou que separou-se do acusado naquele período, em razão do histórico de agressões praticadas por ele, saindo desta cidade no mês de setembro seguinte. Afirmou que somente foi ao encontro do acusado, na casa da genitora deste, conforme haviam combinado, com o objetivo de possibilitar que o réu mantivesse contato com o filho, e deixaria a criança aos cuidados de outros tutores. Asseverou que o intuito de ir à casa da genitora do acusado era apenas possibilitar a visita, mas não para manter contato com ele. Declarou que não convidou o réu a ir à sua casa em momento algum, nem mesmo para buscar a criança. Asseverou que, por mensagens, o acusado a ameaçou naquela data e, embora pedindo que ele ficasse longe de sua casa, ele foi ao local e ali ficou aguardando-a. Consignou que possui as mensagens de tal diálogo consigo. Esclareceu que, após a imposição de medidas protetivas, recebia mensagens dos familiares do réu, dizendo que ele queria contato com o filho e perguntando se poderiam passar o celular para ele e consentiu, pois não achava justo restringir o contato do réu com o filho. Declarou que, em meados de outubro, o réu manteve contato consigo, procurando pelo filho. Disse que, ao voltar para esta cidade, foi à casa da mãe do réu, para informar que o filho do réu lá estava. Esclareceu que,

naquela data, a genitora do réu não estava na casa e quem a recebeu foi uma tia. Não deixou seu filho naquele local. Depois dessa visita, o réu começou a querer ver o filho com frequência. Afirmou que, em nenhum momento, disse ao acusado que queria aproximar-se dele, pois sempre intermediava o contato com familiares.

A testemunha policial militar Jorge Izidoro de Almeida Netto, ouvida em Juízo, relatou que estava com seu parceiro de farda Igor e foi solicitado que atendesse ocorrência de agressão no âmbito de violência doméstica. Narrou que, no local dos fatos, encontrou a vítima na calçada, ensanguentada, com o filho no colo, sendo que o acusado estava dentro da residência e relutava em falar com a equipe policial. Soube pela vítima que ela havia ido à praia com o filho e, ao retornar à sua casa, encontrou o acusado, de quem ela já estava separada. Soube pela vítima que o acusado a questionou sobre onde teria estado e, diante de sua resposta de que foi à praia, ele a agrediu com dois socos, tendo um deles causado um corte em sua testa. Soube, também, pela vítima que em favor dela havia medidas protetivas em vigor, tendo a vítima, ainda, apresentado documento que retratava outra agressão por ela sofrida. Consignou que o réu apresentava comportamento alterado, possivelmente por uso de álcool ou de alguma substância entorpecente, e relutava em sair da casa para falar com a equipe, porém não ofereceu resistência para ser conduzido à delegacia.

Dessa forma, os crimes e sua autoria restaram suficientemente demonstrados.

Nada há nos autos para desacreditar o relato apresentado pela vítima, mesmo porque as lesões por ela afirmadas restaram bem demonstradas pela ficha de atendimento médico de fls. 25.

Em que pese a conclusão do laudo pericial de fls. 206/207 acerca da ausência de elementos sobre a existência de lesão corporal, verifica-se que o exame foi realizado de forma indireta, com base na ficha de atendimento médico, da qual se infere, sem dúvidas, que a vítima, após as agressões, foi atendida em uma unidade hospitalar, onde foi constatado o trauma em sua cabeça, devido à agressão.

A constatação de lesão na ficha de atendimento médico somada à prova oral produzida em Juízo constituem prova suficiente acerca da materialidade do crime de lesão corporal, sendo prescindível o laudo de exame de corpo de delito, à luz do que dispõe o artigo 167 do Código de Processo Penal.

Veja-se, ainda, que as declarações da vítima perante a Autoridade Policial e em Juízo foram harmônicas, esclarecendo como se deu a agressão e a lesão dela resultante.

Sob o crivo do contraditório, a vítima pode esclarecer de forma pormenorizada a conduta praticada pelo acusado na data dos fatos, narrando que, ao retornar para sua casa, o acusado estava à sua porta, pretendendo ingressar em sua residência.

Declarou, então, que o acusado desferiu dois socos em sua cabeça, causando um corte e também inchaço, e esclareceu que sofreu a agressão do réu mesmo estando com seu filho, ainda bebê, em seu colo.

Ressalte-se que, embora a testemunha policial não tenha presenciado a agressão, ela confirmou ter visto a vítima ao lado de fora de sua própria casa, ensanguentada e segurando seu bebê, enquanto o acusado estava no interior da residência da vítima, demonstrando comportamento alterado e recusando-se a sair do local, o que corrobora as declarações fornecidas pela vítima.

Já o acusado optou por alegar que apenas empurrou a vítima para defender-se e que tais fatos teriam ocorrido em local diverso, em uma adega.

Ocorre que, mesmo que se pudesse considerar a versão do acusado de que apenas teria

se defendido da vítima - o que não foi demonstrado por nenhum elemento constante nos autos -, é inequívoco que as agressões praticadas pelo réu dão conta da desproporcionalidade e excesso em sua conduta, estando bem demonstrado o crime de lesão corporal.

Da mesma forma, há prova suficiente quanto ao crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, infere-se dos autos que o acusado estava ciente da decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência nos autos de nº 1542367-09.2021.8.26.0590 que tramitaram perante esta Vara Criminal (fls. 27/29), conforme se depreende da certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 30.

Verifica-se dos autos, inclusive, não haver dúvidas sobre o local onde o acusado foi abordado e detido pelos policiais, ou seja, na casa em que residia a vítima, o que foi admitido pelo réu.

Repise-se que a testemunha policial militar asseverou em Juízo que encontrou a vítima ao lado de fora de sua casa, estando o acusado no interior dela, consignando que ele se recusava a sair do local, o que somente consentiu após diálogo com a equipe policial.

Importante salientar que a vítima esclareceu que, após o deferimento em seu favor das medidas protetivas de urgência, mudou-se de cidade e somente retornou a esta comarca após pedido do acusado para que pudesse manter contato com o filho, e assim agiu para viabilizar as visitas paternas.

Consignou a vítima que, em nenhum momento, demonstrou ao réu ter a intenção de aproximar-se dele, uma vez que sempre intermediava o contato com ele por familiares.

A vítima esclareceu, ainda, que naquela data em que ocorreram os fatos havia combinado que iria até a casa da genitora do acusado, onde deixaria seu filho aos cuidados dos tutores na casa, porém, lá chegando, o réu não estava e a mãe deste pediu que o procurasse.

Disse que, após encontrá-lo bebendo em uma adega, decidiu ir embora com seu filho e, então, o réu passou a enviar-lhe mensagens com conteúdo ameaçador, além de dizer que iria à sua casa, apesar de seus pedidos para que ele permanecesse longe de sua residência.

Portanto, não há dúvidas de que o acusado optou por ir à residência da vítima, para manter contato com ela diretamente, o que demonstra sua intenção em descumprir a ordem judicial estabelecida.

Vale esclarecer que, como é cediço, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevante importância, mormente quando corroborada por fortes indícios de verossimilhança.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício

suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação penal.

2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.

3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ.

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013) (grifos nossos)

Ademais, evidentemente, em crimes dessa espécie, a palavra da vítima deve preponderar, pois não foi comprovada qualquer circunstância que pudesse demonstrar intenção da ofendida de prejudicar o réu.

Da mesma forma, ao revés do alegado pela Defesa, nada há nos autos que indique tenha a vítima tentado, de alguma forma, aproximar-se do acusado para restabelecer com ele qualquer vínculo afetivo.

Ao contrário, depreende-se de suas declarações judiciais que a vítima demonstrou interesse em colaborar com o acusado, viabilizando as visitas ao filho, inclusive retornando a esta cidade e predispondo-se a levar a criança até a residência da genitora do réu para que o contato do acusado com seu filho fosse possível.

Dessa forma, há prova suficiente nos autos para se concluir que o réu efetivamente praticou os crimes a ele imputados.

Feitas essas considerações, passo à dosagem da pena segundo o critério previsto no artigo 68 do Código Penal.

Quanto ao crime de lesão corporal de natureza leve tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 Código Penal, verificando o temor e angústia da vítima por reviver os fatos em audiência, bem como diante de sua narrativa de que a conduta do acusado na data dos fatos não se tratou de fato isolado, e que a aproximação deste a deixava temerosa, evidenciando-se trauma característico das vítimas de violência doméstica e familiar, revelando-se que as consequências do crime se mostraram graves, e verificando-se que o acusado é portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 49, fica a pena aumentada em 1/3, ficando fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal em 1/6, ficando a pena fixada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a reprimenda

acima estabelecida.

Quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11340/06, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 Código Penal, na forma como já referido, verifica-se que o acusado é portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 49, razão pela qual aumento sua pena-base em 1/6, fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública, nos termos da fundamentação já exposta. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em 1/6, ficando a pena fixada em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Oportuno esclarecer que, embora o caso concreto reflita condenação por um crime apenado com reclusão e outro apenado com detenção, o regime deve mesmo ser unificado para fins de determinação do regime inicial, como, aliás, vem decidindo o C. STJ, nos seguintes arestos:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVOSO. CRIMES AUTÔNOMOS. MOMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 15 DA LEI N. 10.826/2003. MOMENTOS DISTINTOS. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO JULGADO SEGUNDO A PRETENSÃO DA DEFESA. INDISPENSABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. MEDIDA INTERDITADA NO ÂMBITO DO REMÉDIO HEROICO. REGIME INICIAL. CONCORRÊNCIA DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMA A ULTRAPASSAR QUATRO ANOS. MODO INTERMEDIÁRIO. REGRAMENTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

VI - Regime inicial. Concorrendo penas de reclusão e detenção, sendo possível a aplicação do regime inicial aberto para ambas, na hipótese em que o somatório delas ultrapassar 4 (quatro) anos, é cabível a aplicação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC n.502.549/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/08/2019; e AgRg no HC n. 578.884/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/03/2021. Assim, a despeito da existência de circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade do paciente, o quantum de pena aplicado reclama o modo intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Agravo regimental desprovido" (AgRg no Habeas Corpus n. 664.602, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. 01/06/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS INSCRITOS NOS ARTS. 288 DO CÓDIGO PENAL E 90 E 96, INCISO IV, DA LEI N. 8.666/1993, C/C OS ARTS. 29, 69 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

5. O agravante foi condenado a uma pena de reclusão de 2 anos e 3 meses e a uma pena de detenção de 6 anos e 6 meses, o que totalizou uma pena de 8 anos e 9 meses. 6. O art. 111 da Lei de Execuções Penais dita que, "quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". 7. Assim, concorrendo penas de reclusão e

detenção, originadas da pluralidade de condenações, o somatório de ambas determina o regime inicial de cumprimento da pena, inexistindo qualquer ilegalidade no acórdão da origem ou na decisão recorrida.8. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Habeas Corpus n. 479.519, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j.14/09/2021)

As penas dos crimes, portanto, deverão ser somadas de acordo com as regras do concurso material de delitos, totalizando 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, observando-se as circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Nos termos do artigo 41 da Lei nº 11.340/06, não é cabível a suspensão condicional do processo.

Por se tratar de lesão corporal e de descumprimento de medida protetiva praticadas na forma de violência doméstica, não poderá o réu beneficiar-se da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante do que dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal, não estando presente um dos requisitos objetivos.

Diante das circunstâncias judiciais negativas, na forma como exposto, incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito dos seus comportamentos no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria bem demonstradas – Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Ré confessa, ademais – Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos – Precedentes – Pena de multa que se corrige – Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante – Regime fechado justificado – Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito – Detração – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais – Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDRÉ LUIZ HORNEAUX DE ALMEIDA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, por incurso no artigo 129, §13, do Código Penal e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, ambos os delitos c.c. o artigo 61, inciso II,

alínea "j", e na forma do disposto no artigo 69 do Código Penal, ficando estabelecido o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se a gravidade dos delitos por ele praticados.

Conforme já decidido anteriormente, em regra, a relevância de se atentar para a proporcionalidade da medida cautelar de prisão preventiva em relação ao provimento final é indiscutível.

Todavia, nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, e pelas características específicas do presente caso, é preciso certa mitigação ao denominado Princípio da Proporcionalidade, sob risco de esvaziamento total do escopo político-criminal da referida Lei.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar do réu, no presente caso, mostra-se ainda necessária para se resguardar a incolumidade física, psicológica e moral da vítima.

Outrossim, o acusado é portador de maus antecedentes e a reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 22 de julho de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA